

기간제 근로자의 고용 보장 법리

— 갱신기대권 법리의 검토 —

김 홍 영*

<目 次>

- | | |
|------------------------|----------------------|
| I. 들어가며 | Ⅲ. 갱신기대권 법리의 비판적 재검토 |
| Ⅱ. 갱신기대권 법리의 구체적인 해석 | 1. 고용 보장 측면에서의 한계 |
| 1. 갱신기대권의 인정 여부 | 2. 새로운 법리의 구상 |
| 2. 갱신 거절의 합리적 이유 인정 여부 | Ⅳ. 결론 |

I. 들어가며

기간제 근로자에게 근로계약 기간의 만료에도 불구하고 계속 고용될 수 있도록 고용을 보장하는 법리로 갱신기대권 법리가 있다. 즉 판례는 “근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다”¹⁾는 갱신기대권 법리를 인정한다.

판례가 형성해온 갱신기대권 법리는, 기간제 근로자에 대해 계속 고용을 보장하려는 사법부의 노력의 산물이라는 점에서, 그 공(功)이 매우 높다. 기간제 근로계약이기 때문에 계약이 갱신될지가 사용자의 자의에 맡겨지고, 그 결과 고용의 불안정이 높아짐은 물론, 노동의 제공 단계에서도 종속성이 심화된다.²⁾ 그간 기간제 사용의 폐해를 완화시키려는 노력을, 판례

DOI: <http://dx.doi.org/10.18018/HYLR.2022.39.2.219>

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수(hongyoung@skku.edu)

1) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등.

2) 김홍영, “사회통합과 비정규직 노동법의 변화”, 『저스티스』 제134-3호, 한국법학원, 2013. 2, 81면.

의 갱신기대권 법리가 수행해 왔다고 평가된다.

연혁적으로 보면,³⁾ 갱신기대권 법리는 기간제 근로자들에게 계속 고용을 보장하는 법리로 작용해오는데 큰 발전을 이루어왔다.

첫째, 갱신기대권은 근로계약 등에서 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신되는데는 취지의 규정을 두고 있는 경우에 국한하여 인정되는 것이 아니라, 나아가 그러한 규정이 없더라도 여러 사정을 고려하여 인정될 수 있다.⁴⁾ 그러한 판례 법리 덕분에, 연구원, 교수 등 전문직에 국한되지 않고, 기간제 근로자들 일반에 대해 널리 갱신기대권 법리가 적용될 수 있어 고용 보장을 위해 활용되어 왔다.⁵⁾

둘째, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 ‘기간제법’이라 한다)이 제정되어 시행된 이후 체결된 기간제 근로계약에도 갱신기대권이 인정될 수 있다.⁶⁾ 기간제법 제4조가 사용자는 2년의 기간 내에서 기간제 근로자를 사용할 수 있음이 원칙이고, 기간제 근로자의 총 사용기간이 2년을 초과할 경우 기간제 근로자는 기간의 정함이 없는 근로자로 본다고 규정하고 있더라도, 입법 취지가 기본적으로 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 근로자의 지위를 보장하려는 데에 있음을 고려하면, 위 규정에 의하여 기간제 근로자의 갱신에 대한 정당한 기대권 형성이 제한되는 것은 아니다. 그러한 판례 법리 덕분에, 기간제법의 시행 이후에도 갱신기대권 법리가 계속 작동할 수 있어 왔다.⁷⁾

셋째, 기간제법 제4조에서 정한 사용기간 제한을 받지 않는 기간제 근로자에 대해서도 갱신기대권이 인정될 수 있다.⁸⁾ 사용기간 제한의 예외 사유에 해당한다는 이유만으로 갱신기대권에 관한 법리의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다. 그러한 판례 법리 덕분에, 사용기간 제한의 예외 사유에 해당하는 기간제 근로자들에게 계속 고용이 보장될 수 있는 계기가 마련된다. 그들은 계속 사용된 기간이 2년이 초과하여도 기간의 정함이 없는 근로자로 전환되

3) 연혁적 고찰에 관해 자세히는, 박은정, “갱신기대권에 대한 판례의 전개와 발전 -1994~2020년 판례의 흐름을 중심으로-”, 『사회법연구』 제43권, 한국사회법학회, 2021. 4, 255-296면 참조.

4) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결 등.

5) 노상현, “기간제 근로계약의 갱신기대권”, 한국노동법학회 편, 『노동판례백선』 제2판, 박영사, 2021, 233면; 김홍영, “사회통합과 비정규직 노동법의 변화”, 『저스티스』 제134-3호, 한국법학원, 2013. 2, 87면; 변성영, “갱신기대권 법리의 재검토”, 『노동법학』 제53호, 한국노동법학회, 2015. 3, 172면 등 참조.

6) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결, 대법원 2017. 10. 12 선고 2015두59907 판결 등.

7) 강성태, “기간제근로자의 갱신기대권과 전환기대권”, 『노동리뷰』 2017년 1월호, 한국노동연구원, 128-129면; 도제형, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리의 적용 가능성 : 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결”, 『노동법연구』 제42호, 서울대학교 노동법연구회, 2017. 3, 204-215면; 김홍영, “기간제법의 시행 이후 갱신기대권의 인정 여부 : 서울고등법원 2011. 4. 14. 선고 2010누33971 판결”, 『노동법학』 제41호, 한국노동법학회, 2012. 3, 365-369면; 김홍영, “사회통합과 비정규직 노동법의 변화”, 『저스티스』 제134-3호, 한국법학원, 2013. 2, 87면 등 참조.

8) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결, 대법원 2019. 10. 31. 선고 2019두45647 판결 등.

는 기간제법상의 보호가 없다. 그들에게 계속 고용의 보장은 갱신기대권 법리에 의해 가능할 뿐이다.⁹⁾

넷째, 갱신기대권 법리의 논의 구조는 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환되리라는 (정규직)전환기대권의 법리,¹⁰⁾ 용역업체 변경의 경우 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 고용승계기대권의 법리¹¹⁾ 등으로 유사한 논의 구조를 새로이 형성하여 고용 보장의 법리의 외연을 확대하고 있다.

이 글에서는 이와 같이 기간제 근로자의 고용 보장에 기여해온 갱신기대권 법리의 구체적인 해석을 전개함으로써 갱신기대권 법리의 적정한 운영을 도모하고자 한다. 갱신기대권이 인정되는지 여부의 판단과 갱신기대권이 인정된다면 갱신 거절에 합리적인 이유가 있는지 여부의 판단을 중심으로 살펴보고자 하겠다.

또한 이 글에서는 갱신기대권 법리가 구체적인 해석과 적용에 있어 기간제 근로자의 고용 보장에 미흡하다는 한계를 드러낼 수 있음을 밝히고자 한다. 그러한 한계는 갱신기대권 법리에 내재되어 있는 한계이므로 그 한계를 극복하기 위해서는 갱신기대권 법리가 아닌 새로운 법리가 필요하다는 점을 제시하고자 한다. 이러한 고찰은 갱신기대권 법리의 구체적인 해석 내용을 전개함으로써 비로소 규명되어질 수 있으므로, 그로부터 논의를 시작하려 한다.

II. 갱신기대권 법리의 구체적인 해석

갱신기대권 법리가 기간제 근로자의 고용 보장을 위해 활용되려면 갱신기대권 법리의 구체적인 해석이 발전하여야 한다. 사용자의 갱신 거절이 정당한지에 관해, 갱신기대권 법리는 ① 갱신기대권이 인정되는지 여부의 판단과 ② (갱신기대권이 인정된다면) 갱신 거절에 합리적인 이유가 있는지 여부의 판단이라는 두 단계로 진행된다. 이하에서는 이를 나누어 구체적인 해석을 전개하도록 하겠다.¹²⁾

9) 김홍영, “고령자이며 정년 후 재고용된 기간제 근로자에게 갱신기대권 법리를 인정한 사례”, 『노동리뷰』 2017년 5월호, 한국노동연구원, 95-98면 참조.

10) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결. 강성태, “기간제근로자의 갱신기대권과 전환기대권”, 『노동리뷰』 2017년 1월호, 한국노동연구원, 129-130면 참조.

11) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결. 강선희, “용역업체 변경 시 고용승계기대권” 『노동리뷰』 2021년 7월호, 한국노동연구원, 101-104면 참조.

12) 이하의 고찰은, 2021년 중앙노동위원회 학술연구용역사업 보고서인 『노동위원회 심판업무 관련 주요 쟁점 사항에 관한 연구』(연구기관: 한국노동법학회, 연구책임자: 유성재) 수록 내용 중 필자가 집필한 “제4장 갱신기대권 판단기준”의 내용을 수정 및 보완한 것임을 밝혀둔다. 그 연구를 위해 2019년과 2020년

1. 갱신기대권의 인정 여부

(1) 유형

기간제 근로계약에서의 갱신기대권은 판례¹³⁾가 인정하는 법리이다. 판례는 ‘근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권’ 즉 ‘갱신기대권’이 인정되는 경우를 두 가지 측면에서 가능하다고 제시한다.

첫째는 ‘근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있’는 경우이다. 이를 ‘규정형’이라 부르도록 하겠다. 규정형의 경우 갱신기대권을 인정하는 논거는 그러한 ‘규정’으로부터 나온다. 갱신과 관련된 규정이 있으므로 갱신 여부가 그에 따라 갱신 여부가 결정되고, 그러므로 갱신에 대한 기대권이 발생한다.

둘째는 ‘그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있’는 경우이다. 이를 ‘제반사정형’이라 부르도록 하겠다. 제반사정형의 경우 갱신기대권을 인정하는 논거는 당사자 사이의 ‘신뢰관계’이다. 그 신뢰관계의 내용은 일정한 요건이 충족되면 갱신된다는 점이다.

(2) 규정형의 구체적 해석

‘근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당

에 판결로 종결된 다수의 사례를 분석하였다. 판결 및 판정 자료를 수집함에 있어 중앙노동위원회 및 관계자의 도움에 감사드린다.

- 13) 기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결).

해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있'는 경우 갱신기대권이 인정된다. '일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지'라는 의미는, 재계약을 위한 '요건이나 절차를 구체적으로 규정'하고 있으면서, 일정 요건을 충족하면 재계약을 해야 한다는 '의무 규정'으로 해석될 수 있는 경우를 말한다.¹⁴⁾ 예를 들면, "이러이러한 경우 '갱신된다'"고 규정하는 방식이다.

반면 규정에 갱신을 결정하는 주체나 절차나 기준 등에 대해 언급하고 있어도 그 기준에 따라 의무적으로 연장되는 것이 아니라, '연장 가능'처럼, 연장될 수 있다는 점을 밝힘에 그치는 경우라면, '일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지'까지 인정할 수 없다. 예를 들면, 인사고과 등을 참작하여 해당 근로자와 재계약을 '할 수 있다'는 정도에 그치는 문구가 있는 경우, '계약기간 만료 후 연장 계약 체결 가능'이라는 문구만 있는 경우,¹⁵⁾ 계약기간을 정하면서 '추후 성과에 따라 연장 가능'이라는 문구만 있는 경우 등은 기준에 따라 의무적으로 갱신된다는 취지가 인정되지 않는다. '연장 가능'의 문구와 함께 '연장계약이 체결되지 아니할 경우 당면퇴직 된다'는 문구까지 아울러 있다면, 일정 요건 충족되면 갱신된다는 취지는 더욱 인정되기 어렵다.¹⁶⁾

(3) 제반사정형의 구체적 해석

일정 요건 충족되면 갱신된다는 규정이 없더라도, '당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있'다면 갱신기대권이 인정된다. 판례가 언급하는 여러 사정은 종합적으로 고려하는 판단요소가 된다.

일부 판정이나 판결에서 갱신기대권을 부정할 때 그 논거로 ① 일정 요건 충족되면 갱신된다는 취지의 규정이 없다는 점, ② 근로계약에 기간이 정하여 있다는 점, ③ 근로자 본인이 그러한 근로계약서에 서명하였다는 점 등을 거론하나, 이러한 점들은 긍정 사례나 부정 사례나 공통된 요소에 불과하므로, 갱신기대권을 부정하는 결정적인 판단요소가 아니다. 갱신기대권을 인정하든 부정하든 그 논거로 여타의 판단요소에 대한 검토를 충실히 하여야 한다.

판례가 언급하는 판단요소인 여러 사정들을 나누어 구체적으로 살펴보겠다. 각각의 사정은 갱신기대권 인정 여부를 판단하는데 '결정적'인 것이 아니라 다른 사정과 함께 '종합적'으로 고려되는 '판단요소'에 해당한다. 따라서 갱신기대권을 인정하는데 궁정적으로 고려되

¹⁴⁾ 변성영, "상대평가에 의한 갱신거절의 정당성", 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 3면 참조.

¹⁵⁾ 대법원 2019. 8. 30. 선고 2019두40680 판결.

¹⁶⁾ 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합69827 판결).

는 사정인지, 부정적으로 고려되는 사정인지로 표현하여 살펴보겠다.

1) 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위

‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’에서 어떠한 점을 살펴보아야 하는지가 문제되는데, 연장이 가능하다고 근로자가 생각할만한 사정이 있는가를 중심으로 판단하여야 한다. 연장이 가능한 기준의 정도에 관해 ‘인사고과가 좋으면’, ‘잘 근무하면’, ‘별다른 일이 없으면’ 등등의 제한된 기준을 제시한 경우뿐만 아니라, 아무런 기준도 생각 없이 막연하나마 연장이 가능하다고 염두에 둘만한 사정이 있다면 갱신기대권의 인정에 긍정적으로 고려된다. 왜냐하면 ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’에서 살펴본 점만으로 갱신기대권을 인정하기에 결정적인 정도가 아니라도 다른 판단요소와 종합적으로 고려할 때 갱신기대권을 인정하는데 긍정적으로 고려될 수 있기 때문이다.¹⁷⁾

다음과 같은 사정들은 갱신기대권을 인정하는데 긍정적으로 고려되는 사정이라 볼 수 있다. 채용 공고, 면접 등 채용과정에서 특별한 사정이 없다면 재계약이 가능하다는 점을 언급한 경우, 채용 공고에서 정규직으로 공고하고서도 실제로는 기간제로 고용되어 근로계약서에 근로계약기간이 기재되어 있는 경우,¹⁸⁾ 근로계약서에 재계약의 단위기간을 규정한 경우¹⁹⁾ 등이다.

반면, 다음과 같은 사정들은 갱신기대권 인정하는데 부정적으로 고려되는 사정이라 볼 수 있다. 업무량 변화에 대응하기 위해 상당수 기간제로 고용하면서 해당 근로자도 단기간의 계약기간을 정한 경우,²⁰⁾ 사용자가 매년 공개채용을 통하여 기간제 강사를 채용하고 당해 근로자도 매년 공개채용에 응시해 합격하여야 재계약하는 경우²¹⁾ 등이다.

17) ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’는 당사자의 진정한 의사를 추정하기 위한 판단요소라는 견해가 있다(변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12. 4면; 하갑래, 『근로기준법』, (주)중앙경제, 2019, 777면). 이 견해는 ‘무엇에 대한’ 진정한 의사인지를 설명하고 있지 않지만, ‘추정하기 위한’이라 말하므로, ‘일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다’는 당사자의 ‘진정한 의사’가 ‘근로계약의 내용, 근로계약이 이루어지게 된 동기, 근로계약 체결 경위 등’을 통해 추정된다는 설명으로 이해된다. 그러나 이러한 설명이 ‘근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위’에서 ‘연장의 일정한 기준을 언급하였는지 여부’를 검토한다면 오히려 갱신기대권이 인정될 가능성을 낮추므로 적절한 해석으로 볼 수 없다.

18) 서울고등법원 2020. 1. 9. 선고 2019누49986 판결.

19) 대전지방법원 2019. 12. 11. 선고 2019구합219 판결은 근로계약서 조항은 ‘재계약자는 3개월 단위로 계약한다’라고 규정하여 단지 갱신가능성을 언급하고 있을 뿐이라고 평가한 후 다른 사정들을 고려해도 갱신기대권이 형성되었다고 인정하기에 부족하다고 판시한다. 그러나 갱신가능성의 언급은 다른 요소와 함께 종합적으로 고려할 때 갱신기대권 인정에 긍정적으로 작용한다고 보아야 한다.

20) 서울행정법원 2019. 5. 16. 선고 2018구합4717 판결.

21) 중앙노동위원회 2020. 8. 5. 중앙2020부해775.

한편 근로계약의 내용에 갱신기대권 자체를 부정하는 명확한 의사를 담은 규정이 있는 경우 갱신기대권이 인정되지 않는다고 판단하는데 ‘결정적’으로 작용한다.²²⁾ 예를 들면, ‘갱신 기대권을 갖지 않는다’, ‘재계약 체결은 사용자의 재량에 따라 결정한다’ 등의 취지를 담은 경우이다.

2) 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태

① 갱신 요건이나 절차의 설정 여부

‘계약 갱신의 기준 등 갱신 요건이나 절차의 설정’이 구체적이어서 의무적인 규정이라면 (예를 들면 ‘이러이러한 경우 갱신된다’라는 규정), 전술한 ‘일정 요건 충족되면 갱신된다는 취지의 규정을 둔 경우’(규정형)에 해당된다. 따라서 그러한 의무적인 규정이 아닌 경우가 여기서는 검토의 대상이 된다.

다음과 같은 사정들은 갱신기대권을 인정하는데 긍정적으로 고려되는 사정이라 볼 수 있다. 취업규칙에 계약만료 시 필요한 경우 재고용할 수 있다고 규정하고 재고용에 대한 심사 절차를 규정하고 있는 경우,²³⁾ 취업규칙에 사용자가 근로자의 건강상태와 근무실적 평정 결과 등을 고려하여 계속 고용할 수 있다고 정한 경우²⁴⁾, 단체협약에 교통사고의 횡수 또는 경중을 기준으로 갱신하지 아니할 사유를 규정한 경우,²⁵⁾ 근로계약에서 특별한 이의사항이 없으면 자동으로 연장된다는 취지의 규정을 두고 있는 경우,²⁶⁾ 약단 단원에 대해 기간 만료 시 특별한 사유가 없는 한 전형을 생략하고 재위촉할 수 있다고 규정한 경우²⁷⁾ 등이다.

반면 다음과 같은 사정들은 ‘갱신 요건이나 절차의 설정’에 해당하지 않는다. 취업규칙에 회사는 근로계약기간이 만료된 경우 근로자를 퇴직시킬 수 있다고 규정한 경우는, 갱신의 가능성을 규정한 것이 아니라, 사용자가 재량적으로 재계약을 체결한다는 취지이기 때문에 갱신기대권을 인정하는데 부정적으로 고려되는 사정이라 볼 수 있다.²⁸⁾ 근로계약에 ‘갱신계약’임을 명시한 부분은 ‘갱신 요건이나 절차의 설정’이 아니나²⁹⁾ 당해 근로자에게 갱신된 사정

22) 김홍영, “사회통합과 비정규직 노동법의 변화”, 『저스티스』 제134-3호, 한국법학원, 2013. 2, 89면.

23) 대전고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누10607 판결.

24) 서울행정법원 2020. 6. 25. 선고 2019구합7171 판결.

25) 서울행정법원 2020. 2. 13. 선고 2019구합70001 판결(그에 해당하지 아니하는 근로자는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신되어 계속 근무할 수 있으리라는 신뢰를 형성할 수 있다).

26) 서울고등법원 2020. 1. 9. 선고 2019누49986 판결, 중앙노동위원회 2019. 6. 14. 중앙2019부해405 등.

27) 서울행정법원 2020. 3. 26. 선고 2018구합79889 판결.

28) 서울고등법원 2019. 7. 18. 선고 2019누30494 판결, 대전지방법원 2019. 12. 11. 선고 2019구합219 판결 등.

29) 서울고등법원 2019. 12. 18. 선고 2019누41197 판결(2차 근로계약을 체결할 당시 ‘계약만료에 따른 갱신’이라는 문구가 기재되어 있기는 하지만, 이는 종전의 근로계약인 이 사건 1차 근로계약과 동일한 내용의 근로계약을 체결한다는 취지의 기재로 보일 뿐임).

은 후술하는 갱신의 실태로서 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려될 수 있다.

② 갱신 요건이나 절차 규정이 없다는 사정의 의미

갱신기대권이 부인된 판결·판정 사례에서는 근로계약 및 취업규칙에 갱신요건·절차 규정을 두고 있지 않다는 점이 당연히 먼저 지적되고 있다. 그러나 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정이 없다는 점만으로 갱신기대권이 확정적으로 부인되는 것이 아니다. 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정은 여러 검토할 사정의 하나일 뿐이다. 그러한 규정이 없는 경우에도 갱신기대권이 인정될 수도 있다는 점에 유의하여 다른 사정들의 검토를 계속하여야 한다. 종합하여 갱신기대권을 인정하기에 충분한지 여부를 판단하게 된다.

갱신기대권이 있다는 점은 이를 주장하는 측이 증명하여야 한다. 결국 여러 사정을 고려하여 충분히 증명되지 않는다면 갱신기대권을 부정하는 결론이 내려진다. 즉 ‘갱신기대권을 인정하기에는 부족하다’는 판단이 내려진다.³⁰⁾

③ 평가표를 사용한다는 사정의 의미

기간제 근로자에 대해 평가표를 작성하여 갱신 여부의 판단에 참조하는 경우 이러한 점이 갱신기대권 인정에 긍정적으로 작용한다. 그렇지만 다른 사정을 더 종합하여 고찰하여야 한다. 사용자가 갱신 여부를 ‘재량적’으로 판단하면서 상급 관리자의 의견을 참조하기 위한 ‘내부 참조용 자료’로서 평가표를 작성하도록 하는 경우도 있기 때문이다. 즉 평가표 사용이 갱신되는 요건을 구체적으로 드러내지 않는다면 갱신기대권을 인정하는데 부족하므로 갱신의 실태를 아울러 살펴보아야 한다.

평가표에서 일정 점수 이상이면 재계약을 한다고 규정하고 그 평가표 양식이 계속 사용되고 있다면, 평가표 양식은 취업규칙에 준하는 성격이며, 의무적인 규정으로 볼 수 있어, ‘규정형’에 해당하여 갱신기대권이 인정된다. 일정 점수 미만이면 재계약하지 않는다고 규정한 경우 반대로 이상이면 재계약이 의무인지는 단정하기 어렵다. 즉 ‘규정형’이라고 까지 볼 수는 없으며, ‘제반사정형’으로 보아야 한다. 그 이상의 점수자에 대해, 특별한 사정이 없다면, 재계약 하는 것이 회사의 방침이라거나, 계속 재계약 해왔다는 실태 등을 더 참조하여 종합적으로 고려한 결과 갱신기대권을 인정할 수 있게 된다.

³⁰⁾ 대법원 2019. 8. 30. 선고 2019두40680 판결(갱신에 관한 요건이나 절차에 관한 규정을 두지 않은 상황에서 인사위원회에서 재계약 여부의 평가를 거친 적이 있다는 사정만으로 향후에도 동일한 절차를 거쳐 재계약 여부를 결정할 것이라는 신뢰를 주었다고 평가할 수 없다고 봄), 대법원 2019. 8. 30. 선고 2019두40680 판결(갱신에 관한 요건이나 절차에 관한 규정을 두지 않은 상황에서 정부의 권고 사항만으로 갱신에 관한 신뢰관계가 형성되었다고 보기 어렵다고 봄) 등.

④ 갱신의 실태

갱신의 실태는 당해 근로자의 갱신 경험 유무뿐만 아니라, 동종의 또는 유사한 기간제 근로자들에 대해 갱신된 사례가 어떠한지, 사업(장)의 기간제 근로자들 전체에 대해 갱신된 사례가 어떠한지 등도 아울러 살펴보아야 한다. 당해 근로자의 개별적인 상황으로부터 갱신에 대한 기대가 형성될 수도 있지만, 다른 근로자들의 전체적인 상황으로 당해 근로자의 갱신에 대한 기대가 형성될 수도 있다. 당해 근로자의 첫 번째 근로계약의 갱신 여부가 문제된 경우도 다른 근로자들에 대한 갱신의 실태를 고려하여 갱신기대권이 인정될 수 있다.

당해 근로자가 여러 회에 걸쳐 계속 갱신되어 왔거나,³¹⁾ 다른 근로자들을 살펴볼 때 전체가,³²⁾ 상당수가,³³⁾ 재계약을 신청한 대다수가,³⁴⁾ 또는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 대부분이³⁵⁾ 갱신되었거나 갱신되어왔다는 점은 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다. 사용자가 특별한 사정이 없는 한 갱신을 해왔다고 밝히거나 일정한 평가를 하여 갱신하였다고 주장하여, 그것이 갱신 여부에 대한 사용자의 정책이라고 인정되는 경우, 갱신의 실태를 보아도 갱신에 대한 신뢰를 인정하여 갱신기대권이 인정될 수 있다.³⁶⁾

반면 다른 근로자들을 볼 때 갱신된 사례가 없거나,³⁷⁾ 상당수가 갱신되지 않아 왔다³⁸⁾는 점은 갱신기대권 인정에 부정적으로 고려된다. 갱신 여부를 재량적으로 판단한 것으로 추측될 수 있기 때문이다. 갱신의 횟수나 기간의 한계를 설정하고 이를 초과한 갱신은 없어왔다는 점도³⁹⁾ 갱신기대권 인정에 부정적으로 고려된다. 갱신에 대한 특별한 기준이 없거나, 평가표는 갱신 여부를 결정하는 재량적 판단을 위한 참고 자료에 불과하며 갱신되지 않은 경우가 상당수 있는 경우라면 사용자의 재량에 따라 갱신된다고 평가될 수 있어 갱신기대권

31) 서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결.

32) 중앙노동위원회 2019. 6. 14. 중앙2019부해405(다른 근로자들은 근로계약이 만료된 이후 별다른 평가 없이 모두 근로계약이 갱신된 경우), 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합58186 판결 등(앞 기수의 동종의 기간제 근로자들은 ‘평가에 따라 계약 연장 가능’이라고 언급하였고 실제로도 예외 없이 재계약되었고, 같은 기수의 동종의 기간제 근로자들 중 당해 근로자를 제외한 모두가 재계약된 경우) 등.

33) 서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결.

34) 대전고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누10607 판결.

35) 서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결(건강상의 문제가 없고 업무상 큰 문제를 일으키지 않으면 근로계약을 갱신하여 왔던 경우).

36) 서울고등법원 2020. 1. 9. 선고 2019누49986 판결(영업 직무 근로자의 경우 근로기간을 정하여 근로계약을 체결한 후 계약 만료 시 영업실적, 근태현황 등을 고려하여 재계약 여부를 결정한다고 사용자가 주장하는 경우).

37) 서울고등법원 2019. 7. 18. 선고 2019누30494 판결.

38) 서울행정법원 2019. 5. 16. 선고 2018구합4717 판결.

39) 대법원 2019. 8. 30. 선고 2019두40680 판결(정년을 경과한 기간제근로자와 2년을 초과하여 근로계약을 연장한 사례는 없는 경우), 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합69827 판결(비정년 트랙 연구직 중 5년을 초과하여 근로계약이 갱신된 사례가 없는 경우) 등.

인정에 부정적으로 고려된다.

당해 근로자에게 근로계약 종료 통보서를 주면서 ‘갱신 거절 사유를 밝힌 점’만으로는 갱신기대권 인정에 무관할 수 있다.⁴⁰⁾ 반면 특별히 발생한 경영상의 어려움을 갱신 거절의 사유로 밝혔다면, 그러한 사정이 예상되지 않았던 상황에서는 갱신기대권이 인정될 수 있다고 판단될 수 있다.⁴¹⁾ 다만 특별히 발생한 경영상의 어려움이 갱신 거절의 합리적인 이유가 되는지는 후속 검토가 필요하다.

3) 근로자가 수행하는 업무의 내용

수행하는 업무의 내용은 해당 업무의 상시성 판단이 그 핵심이다.⁴²⁾ 즉 해당 업무가 상시적인 업무라면,⁴³⁾ 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다. 시설관리 용역계약이 기간이 있어 한시적이더라도 사용자가 시설관리 용역계약을 유지하는 동안에 청소업무는 상시적·지속적으로 수행이 필요한 업무이므로 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다.⁴⁴⁾

반면 해당 업무가 한시적인 업무라면,⁴⁵⁾ 갱신기대권 부정에 부정적으로 고려된다.

4) 그 밖의 사정

상위 관리직 근로자가 근로계약 갱신이 가능함을 언급한 경우 갱신되리라는 신뢰를 가지게 할 수 있으므로 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다.⁴⁶⁾

반면 인사담당자가 갱신을 약속한 자료가 없다는 점은 갱신기대권을 인정하는데 부정적으로 고려된다.⁴⁷⁾

40) 서울고등법원 2019. 12. 18. 선고 2019누41197 판결(갱신 거절 사유를 밝힌 것은, 갱신기대권이 있어서라기보다, 근로계약 종료 사실을 알리면서 단지 계약종료의 이유를 부기한 것에 불과함).

41) 서울고등법원 2020. 1. 9. 선고 2019누49986 판결.

42) 하갑래, 『근로기준법』, (주)중앙경제, 2019, 777면; 변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 5면.

43) 대전고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누10607 판결, 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합58186 판결(기간제 아나운서가 기존 정규직 아나운서들과 동등한 대우를 받으면서 동질적인 내용의 방송 업무 및 그에 부대되는 업무를 수행하였고, 방송 업무는 회사의 주요 사업으로서 당연히 반복적·계속적으로 수행될 것이 예상되고, 이를 위하여 기간제 아나운서들은 상당히 오랜 기간 교육훈련에 임하기도 한 경우) 등.

44) 서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결.

45) 서울고등법원 2019. 7. 18. 선고 2019누30494 판결(요양원의 특성상 입소자의 인원변동을 예측하는 것이 용이하지 아니하여 이 사건 요양원으로서의 영양사의 수를 탄력적으로 운영함으로써 이에 대응할 필요가 있으므로, 영양사들과의 근로계약기간을 설정한 것으로 볼 수도 있음), 대법원 2019. 8. 30. 선고 2019두40680 판결(고위 관리직의 경우 내부 전문가를 육성할 때까지 걸리는 시간을 감안하여 일시적으로 외부전문가를 영입하여 해당 업무를 맡기기로 하였다고 하더라도 이를 불합리하다고 보기 어렵다고 본 사례).

46) 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합58186 판결.

5) 정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우 갱신기대권 인정 여부의 추가적 판단요소

판례는 정년을 경과한 연령의 기간제 근로자에 대해서도 갱신기대권이 발생할 수 있음을 인정한다.⁴⁸⁾ 예를 들면, 정규직으로 근무하다가 정년이 된 후 축적적으로 재고용된 계약기간이 만료되어 재계약 체결 거절이 문제된 경우, 또는 정년 후 연령의 근로자가 새로이 기간제 근로자로 고용된 계약기간이 만료되어 재계약 체결 거절이 문제된 경우 등이 그러하다.

정년 연령을 지났다는 점만으로, 사용자에게 갱신 여부에 대해 재량적으로 하여야 왔다는 증명이 되지 않으며, 또한 갱신기대권을 인정하는데 부정적으로 고려되지도 않는다. 일정한 요건이 충족되면 갱신된다는 취지의 규정을 두지 않은 경우 전술한 여러 사정을 종합적으로 고려하여 갱신기대권이 인정되는지 여부를 판단한다. 아울러 판례는 추가적인 판단요소를 제시하는데,⁴⁹⁾ 그 각각에 대해 살펴보도록 하겠다.

① 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성
취업규칙에 사용자가 근로자의 건강상태와 근무실적 평정 결과 등을 고려하여 계속 고용할 수 있다고 규정한 경우,⁵⁰⁾ 근로계약서에 근로자의 근무성적과 건강상태를 기준으로 회사가 근로계약의 갱신 여부를 결정한다고 규정한 경우⁵¹⁾ 등은 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다.

② 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도

업무의 특성상 연령에 따른 작업능률의 저하나 위험성 증대의 정도가 크지 않은 경우,⁵²⁾ 회사가 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도 등을 고려하여 별도로 기간제 근

47) 서울행정법원 2019. 5. 16. 선고 2018구합4717 판결.

48) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결.

49) 정년을 이미 경과한 상태에서 기간제 근로계약을 체결한 경우에는, 앞서 본 제반 사정 외에 해당 직무의 성격에 의하여 요구되는 직무수행 능력과 당해 근로자의 업무수행 적격성, 연령에 따른 작업능률 저하나 위험성 증대의 정도, 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 실태 및 계약이 갱신되어 온 사례 등을 종합적으로 고려하여 근로계약 갱신에 관한 정당한 기대권이 인정되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 판결).

50) 서울행정법원 2020. 6. 25. 선고 2019구합7171 판결.

51) 대전지방법원 2020. 10. 8. 선고 2019구합1434 판결(근로계약서에 ‘차기년도 근로계약은 전적으로 회사의 근무성적(운행사항, 복장, 친절서비스, 인사, 사고, 차량관리)과 건강상태의 2가지 항목을 검토하여 회사가 결정한다’고 규정하고 있어, 계약해지 사유가 발생하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 회사가 근로자의 근무성적과 건강상태를 기준으로 근로계약의 갱신 여부를 결정하겠다는 취지로 보이는바 근로계약 갱신의 기준이 되는 일정한 요건을 마련한 것으로 봄).

52) 서울고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누36962 판결.

로계약을 갱신하지 않는 사유로 명시한 적이 없으며, 그러한 사정을 들어 거절한 사례도 없는 경우⁵³⁾ 등은 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다.

한편 고령자의 특이성이, 갱신기대권 인정 여부의 판단에서보다, 갱신 거절의 합리적인 이유가 있는지를 판단하는데 추가적으로 고려할 요소로 삼는 것이 더 적절할 수 있다.⁵⁴⁾

③ 해당 사업장에서 정년을 경과한 고령자가 근무하는 실태 및 계약이 갱신되어 온 사례 고령자에 대해서도 회사가 근로자의 근무성적과 건강상태를 기준으로 근로계약의 갱신 여부를 결정해 왔고, 당해 근로자도 수년간 갱신되어 온 경우,⁵⁵⁾ 정년 후 재고용된 경우에도 재고용 평가 규정을 적용하여 갱신 여부를 결정해 왔고, 갱신된 사례가 있는 경우,⁵⁶⁾ 매년 다수가 갱신되었고 해당 근로자를 제외하고는 그간에 특별한 이유없이 계약이 갱신되지 않은 사례는 없는 경우⁵⁷⁾ 등은 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고려된다.

한편 고령자라는 특이성을 반영하여 축적적 재고용의 연령상의 한도를 정하고 이를 초과하여 갱신한 사례가 없는 경우 갱신기대권 인정에 부정적으로 고려된다.

2. 갱신 거절의 합리적 이유 인정 여부

(1) 개요

판례는 “정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없다.”고 한다.⁵⁸⁾ 이는 ‘부당해고와 마찬가지로’는 효력에 관해 서술된 것이지만, ‘부당하게 갱신을 거절하는 것’의 판단 기준을 부당해고의 경우와 마찬가지로 하여야 한다는 것이 아니다.

판례는 갱신을 거절하는데 ‘합리적인 이유’가 있는지를 살펴봐야 한다고 판단기준을 제

53) 서울행정법원 2020. 2. 13. 선고 2019구합70001 판결.

54) 서울고등법원 2019. 12. 13. 선고 2019누39262 판결(택시 운전기사는 장시간 운전 과정에서 상당한 집중력을 유지하면서 도로교통법에 따른 다양한 주의의무를 다하여 승객의 안전을 책임져야 하고, 65세 이상의 고령자는 특별한 사정이 없는 한 그보다 젊은 택시 운전기사보다 시력, 지구력, 체력, 반사신경 등 운전이 필요한 능력이 부족할 수 있고, 그 경우 교통사고의 발생으로 승객이 다치거나 원고 회사에 손해가 발생할 가능성이 있으므로, 회사는 이를 반영하여 재고용 평가 시 65세 이상인 택시운전기사에 대하여는 ‘건강상태’ 항목에서 특이사항이 없다면 일괄적으로 10점을 감점하여 온 것은 특별히 부당하다고 보이지 않는다고 판시함).

55) 대전지방법원 2020. 10. 8. 선고 2019구합1434 판결.

56) 서울고등법원 2019. 12. 13. 선고 2019누39262 판결.

57) 서울행정법원 2020. 2. 13. 선고 2019구합70001 판결.

58) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결.

시한다. 부당한 갱신 거절의 경우 ‘합리적인 이유’가 있는지 여부는 ‘갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단’한다고 판시한다.⁵⁹⁾ 해고의 경우 ‘정당한 이유’가 있는지 여부는 ‘사회통념상 근로관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우’로 판단하는 것과 다르다.

양자의 이러한 차이는 구체적인 사례에서 해고인 경우 정당한 해고라고 보기 힘든 정도의 사유도 갱신 거절인 경우 합리적인 이유가 있는 갱신 거절로 인정될 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 즉 해고의 ‘정당성’보다 갱신 거절의 ‘합리성’이 다소 완화된 기준으로 적용하여, 근로계약의 종료를 좀 더 쉽게 인정한다.⁶⁰⁾ 해고의 정당한 이유로 인정되기 어려운 사유들에 대해 갱신 거절의 합리적 이유로 인정되는 것은, 갱신기대권이 인정되는 기간제 근로계약도 그 본질은 정한 기간이 만료되면 종료되는 것이 원칙인 기간제 근로계약일 뿐이라는 점에 기인한다.⁶¹⁾ 판례도 기간제 근로계약의 종료에 따른 사용자의 갱신 거절은 근로자의 의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 해고와는 구별되는 것이고, 근로관계의 지속에 대한 근로자의 신뢰나 기대 역시 동일하다고 평가할 수는 없다고 본다.⁶²⁾

갱신 거절의 합리적 이유가 있는지는 사용자에게 증명책임이 있다.⁶³⁾ 다만 노동위원회 심판의 경우, 노동위원회에게 조사권한이 인정되므로, 사용자에게 증명책임이 있다는 점을 강조할 필요 없다. 사용자의 주장에 대해 “객관적으로 인정하기에 곤란하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다”고 판단하면 적절하다.

갱신기대권이 인정됨에도 불구하고 사용자가 퇴직사유로 단순히 기간만료라는 점만을 주장하고 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다는 점을 주장하지 않는다면, 갱신 거절의 합리적 이유는 부정된다.

반면 사용자가 기간만료라고 통보서에 기재하였다고 하더라도,⁶⁴⁾ 실제로 갱신을 거절한 사유가 존재한다고 주장하는 경우, 그 사유가 갱신 거절의 합리적 이유가 되는지를 살펴본다.

갱신 거절에 합리적인 이유가 있는지의 판단 시점은 갱신 거절의 시기를 기준으로 판단한다.⁶⁵⁾

59) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결.

60) 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 II』, 박영사, 2020, 79면; 도재형·노상현·최지윤, 『갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구』, 중앙노동위원회 학술연구용역 보고서, 2018, 77면.

61) 변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 9면.

62) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결.

63) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결.

64) 기간제 근로계약이 종료된 후 사용자가 갱신 거절의 통보를 하는 경우에는 근로기준법 제27조에 따라 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 할 의무가 적용되지 않는다(대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114 판결).

(2) 판례가 언급하는 갱신 거절의 합리적 이유에 관한 판단요소

판례는 ‘갱신 거부의 사유와 그 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정한지를 기준으로 판단’한다면서 판단요소를 예시적으로 언급하고 있다.⁶⁶⁾ 즉 ‘사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로계약 체결 경위, 근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여’ 판단한다고 한다.

위 판례가 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다면서 언급하고 있는 여러 사정들은 해고의 정당한 이유인지를 판단하는 판례 법리⁶⁷⁾의 어구와 유사한 구조이다.

갱신 거절의 합리적인 이유를 사회통념에 비추어 판단한다면, ‘사용자의 사업 목적과 성격’, ‘사업장 여건’, ‘근로자의 지위 및 담당 직무의 내용’ 등의 사정을 종합하여 판단하는 것은 당연하다.⁶⁸⁾ 이러한 점에 대해 ‘사업의 목적과 성격’, ‘사업장 여건’, ‘근로자의 지위 및 담당 직무의 내용’을 구체적으로 살펴야 한다.

또한 갱신 거절의 사유로 근로자의 비위행위나 근무태도, 업무역량 등이 주장되고, 그러한 사정 때문에 그 근로자를 다시 일정 기간 사용하지 않겠다는 사용자의 판단이 나름 합리적일 수 있으므로 ‘근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부’의 사정도 고려하는 것은 당연하다.

‘근로계약 체결 경위’, ‘근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태’ 등은, 이미 그 이전에 갱신기대권 인정 여부의 판단요소에도 해당하지만, 갱신 거절의 합리적 이유로 다시 고려할 점이 있는 경우도 있을 수 있다. 경영상의 이유도 갱신 거절의 합리적 이유로 인정될 수 있는데, 경영상의 이유는 ‘근로계약 체결 경위’에 비추어 검토할 수 있겠다. 예를 들면 갱신을 거절한 시점에서 기간제 사용을 축소 내지 폐지하여야 할 필요

65) 서울고등법원 2020. 1. 9. 선고 2019누49986 판결(그 근로자에 대한 갱신 거부 당시 그 근로자에게 책임 있는 사유가 객관적으로 확인되지 않는 등 갱신 거부의 사유와 절차가 사회통념에 비추어 볼 때 객관적이고 합리적이며 공정하다고 보기 어렵다고 봄).

66) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결.

67) 대법원 2003. 7. 8. 선고 2001두8018 판결; 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두10455 판결; 대법원 1998. 11. 10. 선고 97누18189 판결 등. 해고는 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에 행하여져야 그 정당성이 인정되는 것이고, 사회통념상 당해 근로자와의 고용관계를 계속할 수 없을 정도인지의 여부는 당해 사용자의 사업의 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다.

68) 예를 들면, 시설관리 용역계약에 따른 사업은 직원 간의 다툼이 도급계약 유지에 영향이 크다는 점에서 갱신 거절의 합리적 이유를 인정하는데 도움이 되는 요소로 작용한다(서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결).

성이 발생하거나, 신규채용방식으로 전환할 필요성이 발생하는 경우 이러한 점은 ‘근로계약 체결 경위’와 관련된 사정으로 분류할 수 있다.⁶⁹⁾ 또한, 공식적인 근무평가 결과에 따라 갱신을 결정하는 경우에는 갱신요건에 따른 적용이 합리적이어야 한다는 점에서 ‘근로계약의 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부와 그 운용 실태’와 관련된 사정으로 분류할 수 있다.⁷⁰⁾

(3) 근로자에게 책임 있는 사유에 따른 갱신 거절

근로자의 비위행위, 근무태도, 업무능력 등 근로자에게 책임 있는 사유들 때문에 갱신되기 위한 일정한 조건을 충족하지 못하였다면 갱신 거절의 합리적인 이유가 된다.

1) 공식적인 근무평가의 결과에 따라 갱신 여부를 결정한 경우

갱신기대권은 ‘일정한 요건’의 충족을 전제로 ‘갱신’을 예정하고 있는 것이기 때문에, 당사자가 정하거나 또는 당사자 사이에 신뢰관계가 형성된 그 ‘일정한 요건’을 충족하지 못한 경우 갱신 거절의 합리적 이유가 된다. 그러한 일정한 조건이 평가표(또는 심사표)를 통해 구체화될 수 있다. 즉 공식적인 근무평가(근무평정심사) 과정을 거친 결과에 따라 갱신 여부를 결정한 경우가 있다.

판례는 갱신 거절의 ‘사유’와 그 ‘절차’가 사회통념에 비추어 볼 때 ‘객관적’이고 ‘합리적’이며 ‘공정’하여야 한다고 판시한다.⁷¹⁾ 따라서 근무평가(심사)의 기준과 과정에 대해 객관적이고 합리적이고 공정한지를 검토하여야 한다. 자의적이거나 공정하지 않은 평가(심사) 결과에 따라 갱신을 거절한 경우에는 갱신 거절에 합리적인 이유가 인정되지 않는다.⁷²⁾

객관성·합리성·공정성은 평가의 절차 내지 진행 과정에서 특히 엄격히 요구된다.

반면 평가 기준의 구체적인 내용에서는 상대적으로 덜 엄격히 요구된다. 평가(심사) 기준의 구체적인 내용으로 어떠한 항목을 고려해야 하는지, 상대적인 가중치는 어떠해야 하는지 등은 사용자(기업)의 가치판단에 달려있기 때문이다. 바꾸어 말하면, 근로자의 근무태도나 업무능력에서 어떠한 점을 더 중시하는가는 사용자의 재량을 존중하여야 한다.⁷³⁾ 따라서 구

69) 도재형·노상현·최지윤, 『갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구』, 중앙노동위원회 학술연구용역 보고서, 2018, 90-92면. 110-111면.

70) 도재형·노상현·최지윤, 『갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구』, 중앙노동위원회 학술연구용역 보고서, 2018, 92-96면. 110-111면.

71) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결.

72) 예를 들면, 서울고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누36962 판결(회사의 다른 근로자에 대한 평가와 비교하여 보아도 평가의 공정성과 객관성에 의구심이 든다고 봄).

체적 항목이나 배점에 대해 노동위원회나 법원은 사회통념상 ‘현저히 타당성을 결여’하였는지를 기준으로 합리성을 검토함에 그쳐야 한다.⁷⁴⁾ 평가내용으로 정성평가 항목도 포함될 수 있으며, 그것이 객관적 합리성이나 공정성을 결하였는지를 검토하면 족하다.⁷⁵⁾

평가와 관련하여 다음과 같은 사정들은 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 인정하는데 긍정적으로 고려된다. 노사가 협의하여 만든 평가 기준인 경우,⁷⁶⁾ 정기평정 결과에 따른 평정점수의 미달인 경우,⁷⁷⁾ 조직 구성원간의 신뢰관계가 손상되었다고 판단하여 이를 정성평가에 반영한 경우⁷⁸⁾ 등이다. 반면 정성평가에서는 양호한 평가가 나왔으나 정량평가에서 낮은 점수를 주면서 그 채점기준의 합리성에 대해 제대로 설명하지 못하는 경우⁷⁹⁾ 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 인정하기 어렵다.

평가기간은 당해 근로계약의 기간의 사정이 중심이 되겠으나 반드시 그 기간 내의 사정으로 국한된다고 할 수 없다. 근로계약 기간 이전의 최근의 사정도 누적적으로 고려하여 갱신하는데 부정적인 평가를 하는 것이 합리적인 경우가 있을 수 있다.⁸⁰⁾

73) ① 대전고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누10607 판결(외국인 객원연구원 지침에 따라 외국인 객원연구원에 대하여 계약만료 3개월 전에 심사위원회를 통한 재임용심사를 실시하고 있는데, 위 심사는 심사대상자인 객원연구원이 직전학기까지 담당한 교육 프로그램의 강의평가 자료로 진행되며, 학생강의평가(배점 50점)와 심사위원평가(배점 30점)를 합산(80점 만점)하여 대상자의 총점이 50점 미만일 경우 불합격 처리된다. 이와 같은 평가방식은 영어회화 등 강의를 담당하는 외국인 객원연구원의 업무 중 가장 본질적인 업무인 강의업무의 적정성과 수강생의 만족도를 기초로 한 것으로 그와 같은 평가방법 및 기준이 불합리하다고 보기 어렵다.), ② 중앙노동위원회 2019. 9. 3. 중앙2019부해787(이 사건 체육회의 근무평정은 3개 분야(사명감 및 봉사정신, 인화단결 및 협조성, 프로그램 운용 능력 등)의 정성평가와 2개 분야(근태관리 및 현장평가, 지도자교육수료)의 정량평가로 구분되며, 정성평가의 경우 객관적인 판단 기준이 마련되어 있지 않은 것으로 보이나, 평가와 관련한 평가항목과 평가방법의 선택 등에 있어서 사용자에게 상당한 재량이 있다고 보아야 할 것이고 평가과정에서 평가자의 주관적 의사가 반영될 수 있는 정성평가에 의해서만 결정되지 않고, 정량평가도 평가에 합산되므로 평가의 객관성 및 공정성이 결여되었다고 단정하기 어렵다.).

74) 변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 15면.

75) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009두5374 판결.

76) 서울고등법원 2019. 12. 13. 선고 2019누39262 판결.

77) 서울행정법원 2020. 7. 17. 선고 2019구합79305 판결.

78) 중앙노동위원회 2019. 9. 3. 중앙2019부해787(이 사건 근로자는 정직 3월의 징계처분을 받은 전력이 있고, 정직기간 중에도 계속하여 동료근로자, 전라남도체육회, 이 사건 사용자를 상대로 지속적으로 민원을 남발하고, 동료 근로자에 대해서도 검찰에 진정·고소를 제기하였으나 대부분 ‘혐의 없음’으로 처리된 점 등에 비추어 보면, 이 사건 사용자가 조직 구성원간의 신뢰관계가 손상되었다고 판단하여 이를 정성평가에 반영한 것을 두고 부당한 평가라고 보기 어려움).

79) 서울고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누36962 판결(정성평가에서 다소 소극적이라는 내용은 있으나 직무지식을 구비하고 주어진 업무를 성실히 수행한다는 양호한 평가를 하였음에도 정량평가에서 재계약을 보류하는 평가를 하는 등 상반된 평가를 하여 근무평가가 공정하고 객관적으로 실시되었다고 보기 어렵다고 봄).

80) 서울고등법원 2019. 12. 13. 선고 2019누39262 판결(택시운전기사의 교통사고 전력은 승객의 안전과 밀

평가기준과 관련하여 하위 일정 % 내지 일정 순위 아래를 재계약하지 않는다는 상대적인 선별 기준도, 판례는 위법하다고 보지 않는다.⁸¹⁾ 갱신기대권이 인정되는지 여부의 판단에서 상대적인 선별이라는 일정한 기준을 충족하면 갱신되리라는 갱신기대권이 인정되기 때문이다. 이처럼 갱신기대권이 발생하게 되는 갱신의 일정한 요건을 어떻게 구체화하는가는 사용자에게 상당한 재량이 인정된다는 점에서 갱신기대권 법리는 한계가 존재한다. 다른 법리에서는 상대적인 평가 방식이 정당하거나 합리적이지 못하다고 보는 경우가 있다. 근무성적이나 근무능력의 불량을 이유로 하는 해고의 정당성 판단에서는, 근무성적이나 근무능력이 다른 근로자에 비하여 상대적으로 낮은 정도를 넘어 상당한 기간 동안 일반적으로 기대되는 최소한에도 미치지 못한 정도가 되어야 해고의 정당한 이유로 검토될 수 있다.⁸²⁾ 시용 근로자에 대해 본채용 거부의 유보된 해약권 행사에 합리적인 이유가 있는지의 판단에서, 상대적인 평가 결과만으로는 업무적격성을 판단하는 시용 제도의 취지에 비추어 합리적인 이유로 인정되지 않는다.⁸³⁾ 반면 경영상 이유에 따른 해고에서는 합리적이고 공정한 기준에 따라 해고대상자를 선정함에 있어 궁극적으로는 해고 인원에 맞추어 해고 대상자를 상대적으로 선별하게 된다(근로기준법 제24조 제2항 참조). 경영해고에서는 존속되는 일자의 한도가 있어 상대적으로 인원을 선별하는 것으로 합리적인 이유가 된다. 그러나 기간제 근로계약의 갱신 거절에서는 일자리가 존속하는데도 미리 제시된 상대적인 선별에 따라 갱신이 거절되고 다른 근로자를 새로이 채용하는 것이 합리적인가에 대해 의문이 발생하게 된다. 이 때문에 판례가 인정하는 갱신기대권 법리가 기간제 근로자의 고용 보장에 충분하지 못하다고 비판하는 것이다.

접한 관련이 있으므로, 해당 근로계약의 계약기간 내에 발생한 교통사고뿐 아니라 그 이전에 발생한 교통사고도 재고용 평가에 반영되어야 할 필요성이 있음).

- 81) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009두5374 판결(계약직 근로자들에게는 근무성적 평가 결과 일정한 순위 이상의 성적을 얻게 되면 기간제 근로계약이 갱신되리라는 정당한 기대권이 인정된다고 봄이 상당하고 봄).
- 82) 대법원 2021. 2. 25. 선고 2018다253680 판결(사용자가 근로자의 근무성적이나 근무능력이 불량하다고 판단한 근거가 되는 평가가 공정하고 객관적인 기준에 따라 이루어진 것이어야 할 뿐 아니라, 근로자의 근무성적이나 근무능력이 다른 근로자에 비하여 상대적으로 낮은 정도를 넘어 상당한 기간 동안 일반적으로 기대되는 최소한에도 미치지 못하고 향후에도 개선될 가능성을 인정하기 어렵다는 등 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도인 경우에 한하여 해고의 정당성이 인정됨).
- 83) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결(시용조건부 근로계약 해지의 성격상 당해 근로자의 업무적격성 등을 절대적으로 평가하여야 하는데, 상당수의 평정자가 다른 직원들과의 비교를 통하여 평가한 것은 상대적인 평가가 아니나, 은행이 각 지점별로 C 또는 D의 평정등급 해당자 수를 할당하였고, 근무성적평정표 및 평정의견서만으로 시용 근로자들의 업무수행능력이 어느 정도, 어떻게 부족하였는지 또 그로 인하여 업무수행에 어떠한 차질이 있었는지를 알 수 없는 점 등에 비추어 보면, 은행이 시용 근로자들과의 근로계약을 해지한 데에는 정당한 이유가 있다고 보기 어려움).

2) 공식적인 근무평가 과정이 없는 경우

이 경우에는 갱신 거절의 이유로 사용자가 주장하는 사유, 근로자의 비위행위, 근무태도, 업무능력에 대해 사용자가 내린 판단에 대해 합리적인 판단인지를 검토하여야 한다.

평가표 등의 객관적인 자료가 제시되지 않았다는 점, 바꾸어 말하면 공식적인 근무평가 과정을 거치지 않았다는 점만으로, 사용자의 주관적인 판단이라 단정하여서는 안된다. 사용자가 주장하는 갱신 거절의 사유가 사용자의 사업 목적과 성격, 사업장 여건, 근로자의 지위 및 담당 직무의 내용, 근로자에게 책임 있는 사유가 있는지 여부 및 그 사유의 경중 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 사회통념에 비추어 볼 때 갱신을 거절할 만한 사유인지를 판단하여야 한다.

예를 들면, 다음과 같은 사정들은 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 인정하는데 긍정적으로 고려된다. 잦은 업무실수,⁸⁴⁾ 잦은 지각으로 근무태도 불량,⁸⁵⁾ 동료 직원 간의 다툼,⁸⁶⁾ 징계를 받은 사실,⁸⁷⁾ 신뢰관계 훼손⁸⁸⁾ 등이다.

사용자가 주장하는 사유들을 증명할 객관적인 증거가 없는 경우 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 인정되지 않는다.⁸⁹⁾ 갱신된 다른 근로자들과 비교하여 근로자의 잘못이 중하지 않다는 사정은 갱신 거절의 합리적인 이유가 있다고 인정하는데 부정적으로 고려된다.⁹⁰⁾

(4) 경영상 이유에 따른 갱신 거절

1) 기간제 근로자의 사용의 감축

기간제 근로자 고용 계기의 상실, 해당 업무의 업무량 수요의 감소 및 해당 업무의 폐지

84) 중앙노동위원회 2019. 6. 14. 중앙2019부해405.

85) 대전고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누10607 판결.

86) 서울행정법원 2019. 6. 20. 선고 2018구합5239 판결(동료 직원 간의 다툼. 경위서 제출하라는 지시에 불응. 5회에 걸쳐 지각 등을 고려함).

87) 서울고등법원 2019. 4. 3. 선고 2018누68416 판결(징계를 받은 사실을 갱신 거절의 합리적 이유에서 고려하는 것은 이중징계에 해당하지 않음).

88) 중앙노동위원회 2019. 6. 14. 중앙2019부해405(원청에 사용자인 회사의 업무처리가 부적절하다는 내용의 투서를 함으로써 원청으로부터 도급을 받아 사업을 경영하는 사용자를 곤란하게 만들어 신뢰관계를 크게 훼손하였고, 투서내용이 객관적 사실에 근거한 주장인지 여부가 불분명하다고 봄).

89) 예를 들면, 서울고등법원 2020. 7. 16. 선고 2020누36962 판결(회사는 이 근로자가 상사의 지시에 따르지 않았거나 직원들과의 관계가 원만하지 않다거나, 업무능력이 부족한 사실을 증명할 객관적 증거를 제출하지 못함).

90) 서울고등법원 2019. 11. 15. 선고 2019누39927 판결(버스 운전기사인 이 근로자가 갱신 거절 전의 1년 동안 재계약 심의위원회의 심의 결과 재계약을 체결한 다른 근로자들이나 이 근로자와 유사하거나 가벼운 수준의 징계를 받았던 다른 근로자들의 경우와 비교하여 볼 때, 이 근로자가 교통사고를 야기한 횡수가 월등히 많거나 교통사고의 규모나 그로 인한 피해가 현저히 크다고 보기 어려움).

등 기간제 근로자의 사용을 감축하려는 사용자의 경영상 이유도 갱신 거절의 합리적 이유가 될 수 있다.

경영상의 이유는, ‘일정한 요건’을 충족하면 갱신되리라는 기대를 형성하는데 있어 ‘일정한 요건’으로 미리 제시되는 경우가 아마 드물 것이다. 일정한 요건으로 제시되지 않더라도, 기간제 근로자의 사용을 감축한다는 경영상의 이유가 갱신 거절의 합리적 이유로 추가적으로 인정될 수 있는데, 이는 기간제 근로계약의 본질적 특성에 따른 사유⁹¹⁾이기 때문이다.

경영상 해고의 경우는 긴박한 경영상의 필요가 있어야 하고, 해고회피노력을 다하여야 비로소 경영상 해고가 가능할 수 있다. 전체 근로자 또는 기간제 근로자들에 대해 경영상 해고가 가능한 상황에서야 기간제 근로자에 대해 갱신 거절이 가능해지는 것은 아니다. 오히려 경영상 해고가 정당하기 위한 해고회피노력의 예로 기간제 고용의 재계약 거부가 거론된다. 이에 비추어 보아도 경영상 해고를 하는 정도가 아닌 상황에서 그전 단계에서 기간제 근로자에 대해 경영상 이유에 따른 갱신 거절이 합리적인 이유로 인정될 수 있다.

기간제 근로자의 사용을 감축한다는 경영상 판단은 사용자의 경영적 의사 결정에 맡겨져 있어 특정 시기에 그 판단이 정당한지를 사법 심사하기는 쉽지 않다. 예를 들면 특정 시기에 기간제 근로자의 갱신을 거절할만한 정도로 인력 운용이나 재정적인 어려움에 직면하였는지를 객관적으로 사법 심사하기는 어렵다. 당해 근로자로서는 종전까지는 다른 근로자에 대해 갱신기대권에 따라 갱신해오다가 자신의 경우에 경영상의 이유를 들어 갱신을 거절하는 것이 부당하다고 여길 것이다. 그렇지만 갱신 거절의 대상 시점을 선택하는데 있어 사용자가 제시하는 자료에 비추어 자의적인 판단⁹²⁾이 아니라면 그 결정이 부당하다고는 볼 수 없다고 노동위원회·법원은 소극적으로 사법 심사를 하여야 할 것이다.⁹³⁾

같은 시기이거나 또는 인접하여 사실상 같은 시기로 볼 수 있는 시기에 여러 명의 갱신 대상자 중에서 일부만을 선택하여 갱신한 경우, 그 선택의 기준과 적용이 합리적이고 공정한지를 판단하여, 합리적인 이유없이 특정인에 대해 차별을 하는 것은 갱신 거절의 합리적인 이

91) 변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 10면.

92) 예를 들면, 서울행정법원 2020. 11. 26. 선고 2019구합87771 판결(이 근로자는 월 435만 원 상당의 상대적으로 높은 급여를 지급받고 있었으나, 사무총장과 면담할 당시 급여를 낮추는 조건으로 근로계약을 갱신하는 방안도 함께 논의되었고, 협회는 이 사건 근로계약 종료 무렵에는 정상적으로 운영되고 있었으며 이 근로자에 대한 근로계약을 갱신하지 못할 정도로 재정상 어려움이 계속될 것으로 전망되는 상황도 아니었음).

93) 예를 들면, 서울행정법원 2019. 7. 18. 선고 2018구합73270 판결(기간제 근로자가 담당한 업무가 상시적이고 계속적인지 여부를 판단함에 있어서는 당해 업무 자체의 객관적 내용뿐만 아니라 당해 업무에 인력을 충원·유지할 필요성도 함께 고려하여야 함. 회사의 업무 상황이 변화하여 더 이상 ‘해외사업 전문가’를 별도의 인력으로 충원·유지할 필요성이 소멸하였다면, 그러한 사유는 계약갱신을 거절할 합리적인 사유라고 볼 수 있음).

유가 되지 않는다. 이 점은 비교적 엄격하게 사법 심사가 가능할 수 있겠다.

2) 신규채용절차로 대규모 갱신 거절

사용자가 종전과 달리 기간제 근로자에 대해서도 신규채용절차에 응해 합격하여야 재고용된다고 주장하면서 대규모로 갱신을 거절하는 경우가 있다. 기간제 근로자에게 이미 계약기간 동안 갱신기대권이 인정되어왔다고 볼 수 있는 사건에서, 이는 신규채용절차를 이유로 이미 형성된 갱신기대권을 배제하는 것이 된다. 이러한 점도 경영상의 이유로 갱신 거절의 합리적인 이유가 될 수 있는지가 문제된다.

판례는 신규채용절차를 제시하여 근로자의 갱신에 대한 정당한 기대권을 전면적으로 배제하는 조치에 대해, “사용자로서 그와 같은 조치를 취하지 않으면 안 될 경영상 또는 운영상의 필요가 있는지, 그에 관한 근거 규정이 있는지, 이를 회피하거나 갱신 거절의 범위를 최소화하기 위한 노력을 하였는지, 그 대상자를 합리적이고 공정한 기준에 따라 선정하기 위한 절차를 밟았는지, 그 과정에서 차별적 대우가 있었는지 여부 등을 종합적으로 살펴보고 그 주장의 당부를 판단하여야 한다.”고 본다.⁹⁴⁾

판례 법리에 대해 경영상 해고에 준하는 기준을 제시하였다는 점에서 긍정적으로 평가하는 견해가 있다.⁹⁵⁾ 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하겠지만,⁹⁶⁾ 판례 법리는 신규채용

⁹⁴⁾ 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결. 대법원은 교향악단이 위촉기간이 만료되는 기존 단원들에 대해 재위촉 전형을 하지 않고 일제히 신규전형을 통해 단원을 선발할 목적으로 사전 동의 또는 협의 등의 절차를 거치지 않은 채 공개전형을 실시하여 대규모로 연주자들의 재위촉을 거부한 데에는 합리적인 이유가 없다고 보았는데, 그 이유로 다음을 제시한다. ① 재위촉 전형을 하지 않고 신규전형을 통해 재위촉 거부를 하여야 할 경영상 또는 운영상의 필요가 있었음을 뒷받침하기에 충분한 사정을 찾아보기 어렵다. ② 조레나 시행규칙 등을 개정하는 등의 방법으로 그 근거를 마련하거나 또는 단원들과 사전 협의를 하는 등의 절차를 거친 바가 없다. ③ 공개전형을 실시하면서 응시자격을 해당 지역 거주자로 제한한 것은 국민의 거주이전의 자유 및 직업선택의 자유를 보장하여야 한다는 측면에서 보아도 합리적이고 공정한 절차라고 보기 어렵다. 아울러 대법원 판결에서는 직접적인 이유로 거론하지는 않지만 전술한 판단요소에 비추어보면 가점 부여 등의 구체적인 기준도 마련하지 않은 점도 합리적인 이유를 인정하는데 부정적으로 고려된다.

⁹⁵⁾ 박은정, “갱신기대권에 대한 기대의 갱신: 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결”, 노동법실무연구회 편, 『노동법실무연구 III』, 2021, 155면은 “경영상 필요에 따라 갱신기대권을 제한하려고 하는 시도에 대해서는 근로기준법상 경영상 해고 규정에 준하는 요건을 필요로 한다고 본 것은, 기업의 구조조정이나 경영합리화라는 목적을 달성하기 위해 기간제 근로자들의 갱신기대권의 실현을 회피하고자 하는 시도를 막는 분명한 지침을 주었다.”고 긍정적으로 평가한다.

⁹⁶⁾ 예를 들면, 서울행정법원 2020. 3. 5. 선고 2019구합58186 판결. 기존 기간제 아나운서들을 재계약을 결정하는 특별채용 절차를 신규 채용하는 일반채용 절차와 같은 평가기준을 적용하고 선발인원을 구분하지도 않아 기존 기간제 아나운서들은 전부 재계약이 거절된 사례에서 법원은 갱신을 거절한 것은 합리적인 이유가 없다고 보았다. 그 이유로 다음을 제시한다. ① 인사규정에 따라 특별채용 절차는 공개경쟁 시험을 원칙으로 하는 일반채용 절차와 구분되는데도 이를 따르지 않았다. ② 근무성적을 고려하는 취지의 인사규정이 있음에도 근무성적을 평가기준으로 고려하는 노력을 하지 않았다. ③ 같은 시기 입사하여

절차로 전환하여 갱신기대권을 전면적으로 배제하는 조치가 정당할 수 있음을 인정한다. 기존의 재계약 절차를 신규채용 절차로 전환하여야 할만한 경영상의 필요성은 엄격히 판단되어야 할 것이다.

III. 갱신기대권 법리의 비판적 재검토

1. 고용 보장 측면에서의 한계

위와 같이 갱신기대권에 관해 구체적으로 해석을 검토함으로써 갱신기대권이 기간제 근로자의 고용 보장 측면에서 한계가 있음이 드러난다.

첫째, 갱신기대권의 인정 여부는 당사자 특히 사용자의 의사에 따라 결정될 수 있어 고용 보장에 미흡하다.

규정형의 경우 갱신기대권은 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 갱신의 요건과 절차를 두고 있어 이에 따르겠다는 당사자의 의사에 근거한다. 즉 규정형은 갱신기대권을 인정하는 당사자의 의사의 결과일 뿐이다. 사용자가 규정형을 받아들여야 갱신기대권이 인정될 수 있을 뿐이다.

제반사정형의 경우 사용자가 갱신기대권의 인정에 긍정적으로 고려될 요소들을 제거하고 부정적으로 고려될 요소들을 만들어 의도적으로 관리한다면 갱신기대권이 인정되지 못한다. 제반사정형의 갱신기대권이 인정되는 경우는 사용자가 갱신기대권이 인정되지 않도록 유의하여 제반 사정들을 제대로 관리하지 못한 소극적인 결과이거나, 또는 사용자가 갱신기대권이 인정되어도 적절한 이유가 있다면 갱신을 거절할 수 있으므로, 즉 합리적인 이유가 있으면 갱신 거절이 가능하므로, 갱신기대권의 인정을 용인한 결과일 뿐이다.

나아가 사용자는 근로계약에 갱신은 사용자의 재량에 따른다거나 갱신기대권이 부정된다는 내용의 규정을 둬으로써 갱신기대권이 인정되지 못하도록 할 수 있는 길이 열려있다.

둘째, 갱신 거절의 합리적인 이유의 구체적인 내용에 관해 사용자의 재량이 작용할 수 있다는 점에서 고용 보장에 미흡하다.

평가의 절차적 공정성도 평가 절차와 기준을 사용자가 스스로 설정한 경우에만이 논할 수 있는 구조이다. 평가표에 의해 자세히 기준을 정하는 경우 갱신기대권 인정에 긍정적으로 고

근무한 다른 분야 계약직 근로자들이 전부 특별채용된 것과 대조적으로 아무도 선발되지 못하였는데, 이러한 결과를 납득할 수 있을 정도의 사정이 나타나지 않는다.

려될 뿐만 아니라 갱신 거절의 합리적인 이유를 판단하는데도 구속적이어서 사용자에게는 불리할 수 있기 때문에, 사용자가 그렇지 않도록 유의한다면 결국 평가의 절차적 공정성을 문제 삼기 어렵다. 평가표에 의해 자세히 기준을 정하는 것이 반드시 요구되는 것도 아니다. 나아가 그러한 평가표를 단순히 참고자료로 사용할 뿐이며 갱신 여부에 대해 사용자가 재량적으로 결정하여왔다는 실태는 갱신기대권 인정에 부정적으로 고려된다. 갱신기대권 법리가 과연 사용자에게 평가표에 의해 공정한 판단을 하도록 강제하거나 최소한 그리하도록 유도할 수 있는지 의문이다.

평가 기준의 세부적인 평가항목에 있어서도 사용자가 어떻게 구성하는지에 대해 상당한 재량이 인정된다. 합리적이고 공정한 기준이 되는지에 대해 상위의 지도 이념이 없기 때문이다. 경영해고인 경우에는 사용자의 경영상의 필요성과 근로자의 고용 보장이라는 두 가지 측면으로부터 해고대상자 선정 기준을 경영 기준과 사회적 기준을 고려하도록 재검토할 수 있다.⁹⁷⁾ 시용 근로자의 본계약 체결 거부 사유에서도 업무적격성의 판단이라는 취지에 비추어 평가 기준의 합리성이 검토된다.⁹⁸⁾ 이와 비교하여 갱신기대권은 사용자가 설정한 갱신의 요건에 대해 그 부적절함을 논하기에 한계가 있다.

나아가 갱신기대권 법리에서는 평가 기준으로 상대적인 선별도 받아들여진다는 점에서도 고용 보장에 미흡하다. 다른 근로자와 비교하여 상대적으로 못하다는 점을 내세워, 일자리가 존속되고 있음에도 기간제 근로자의 교체가 가능할 수 있다.

결국 갱신기대권의 법리는 갱신기대권을 인정할지 안할지, 인정한다 해도 다시 갱신 거절의 합리적인 이유와 관련하여, 갱신의 기준과 절차를 어떻게 할지 등에 관해 사용자의 의사 내지 재량이 관철될 수 있는 한계가 존재한다. 이러한 한계는 기간제 근로자가 근무해온 일자리가 존속되고 있음에도 다른 기간제 근로자로 대체함으로써 그 기간제 근로자의 고용 보장에 충실하지 못하게 된다. 기간제 근로자의 일자리가 존속하고 있어 계약기간 만료되었어도 계속 고용할 수 있음에도 불구하고, 그 기간제 근로자에게 계속 고용을 중단할만한 정도로 그 근로자에게 책임이 있는 특별한 사정이 있거나 사용자에게 경영상 특별한 사정이 있다면, 그러한 경우에 한하여 갱신이 거절될 수 있을 뿐인 법리라면, 기간제 근로자에게 고용 보장에 충실할 수 있다. 갱신기대권 법리는 그 정도로 고용 보장을 하고 있지 못하다.

97) 대법원 2021. 7. 29. 선고 2016두64876 판결(해고대상자 선정기준은 단체협약이나 취업규칙 등에 정해져 있는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그에 따라야 하고, 만약 그러한 기준이 사전에 정해져 있지 않다면 근로자의 건강상태, 부양의무의 유무, 재취업 가능성 등 근로자 각자의 주관적 사정과 업무능력, 근무 성적, 징계 전력, 임금 수준 등 사용자의 이익 측면을 적절히 조화시키되, 근로자에게 귀책사유가 없는 해고임을 감안하여 사회적·경제적 보호의 필요성이 높은 근로자들을 배려할 수 있는 합리적이고 공정한 기준을 설정하여야 한다.)

98) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2002다62432 판결.

이러한 갱신기대권의 한계의 근원은, 갱신기대권이 법률에 명문의 규정을 두고 있지 못하고, 단지 판례를 통해 형성된 법리라는 점에 있다. 판례 법리는 갱신기대권의 법적 논거를 헌법 제32조의 근로권 보장 및 근로기준법 제23조 제1항의 해고이유 제한으로부터 직접적으로 도출하지 못하였다. 강행적 법질서 자체가 아니라, 당사자 간의 신뢰, 기대 등의 개념 도구를 사용하여 법적 논거를 형성했을 뿐이다.

2. 새로운 법리의 구상

근로자의 고용 보장을 위해 국가가 외부노동시장을 활성화하고 다른 일자리로 고용이 계속되도록 조치하는 것도 방법이 될 수 있다. 다른 측면에서, 당해 사업장에서 고용이 계속되도록 함으로써 고용을 보장하는 방법도 있다. 후자의 방법이 근로자의 고용 보장에 중요한 방법이라면 우리의 법제도는 이를 실현하는 모습이 되어야 한다.

우리의 근로기준법은 정당한 이유가 없는 해고를 제한하는 방법(제23조 제1항)으로 근로자의 고용을 보장한다. 이러한 고용 보장의 방법이 근로계약 기간이 만료하는 경우에는 철저히 못하다. 왜 그럴까? ‘해고’는 사용자의 일방적인 의사에 의해 고용이 종료되는 것이고, 근로계약기간의 만료는 원칙적으로 ‘해고’가 아니며, 갱신기대권이 있음에도 합리적인 이유 없이 갱신을 거절하는 경우에만 예외적으로 ‘해고’에 해당한다는 일반적인 해석론이 계속 받아들여지고 있기 때문이다.

판례는 “기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다.”라고 한다.⁹⁹⁾ 그러나 근로계약 기간이 만료되는 경우에도 근로자에게 계속 고용을 보장하기 위해서는 종전과는 다른 다음과 같은 새로운 법리로 해석이 필요하다.

- ① 근로자와 사용자는 근로계약에 기간을 정할 수 있다. 그러나 근로계약의 기간이 만료되는 경우에도 그러한 사정만으로 고용¹⁰⁰⁾이 종료되지 않는다. 왜냐하면 근로계약기간이 만료되는 경우에도 그 근로자에게 계속하여 고용이 보장될 수 있어야 헌법 제32조가

⁹⁹⁾ 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결.

¹⁰⁰⁾ ‘고용’이라는 용어보다 ‘근로관계’ 또는 ‘노동관계’라는 용어가 더 적절할 수 있겠으나, 이 글에서는 이해의 편의상 ‘고용’이라는 용어를 쓸 뿐이다. 노동관계(근로관계)는 고용, 도급, 위임 또는 그 밖의 다양한 계약유형으로 나타날 수 있어 고용이라는 용어를 사용함으로써 오해의 소지가 있다는 점이 우려된다. 용어에 대한 문제는 앞으로 더 면밀히 검토되어야 바람직하다.

규정하고 있는 근로권이 근로자에게 고용을 보장하는 취지에 충실할 수 있기 때문이다.¹⁰¹⁾

- ② 근로계약의 기간은 근로자가 장기간 계약에 구속되는 것을 방지하려는 취지에서 인정된다. 따라서 근로자는 근로계약기간의 만료에 따라 자유롭게 퇴직할 수 있다.
- ③ 근로계약의 기간이 만료에 따라 근로자가 근로계약의 갱신을 요구하는 경우 사용자는, 다음과 같이 정당하게 고용을 종료할 수 있는 사유가 없는 한, 일방적인 의사로 고용을 종료할 수 없다. 그 근로자가 일해 온 일자리가 계속 유지되지 않거나 고용의 조정이 필요한 경영상의 이유가 있는 경우 또는 그 근로자의 고용을 계속할 수 없을 정도로 그 근로자에게 책임이 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자가 이를 근로자에게 밝히고 고용을 종료할 수 있다. 그러한 사정이 없음에도 사용자가 일방적으로 고용을 종료하는 행위는 부당한 해고에 해당한다.
- ④ 위의 고용을 종료할 수 있는 정당한 이유가 인정되지 않는다면, 근로자와 사용자 사이에 종전과 동일하게 기간을 정하여 근로계약을 갱신하여 체결된 것으로 본다.

이러한 새로운 법리는, 해고, 근로계약 기간, 갱신기대권 등에 관한 기존의 판례 및 일반적 인 해석론과 상충하므로, 쉽게 받아들여지지 못할 수 있다. 근로기준법에 명문의 규정을 두는 입법적인 해결을 해야만 그러한 새로운 법리가 전개될 수 있게 되는지 고민스러운 지점이다.

입법론적 측면에서 볼 때, 단지 현재의 갱신기대권에 관한 판례 법리의 내용을 그대로 입법하는 것은 적절한 논의 방향이 아니다. 갱신에 대한 신뢰나 기대가 어떠한 경우에 형성되는지, 합리적인 이유는 어떻게 구체적으로 설명될 수 있는지에 관해, 고용 보장 법리에 미흡한 해석론이 입법 이후에도 그대로 지속될 수 있기 때문이다.

입법은 새로운 법리에 따라 새롭게 구상하여야 한다. 다음과 같이 기간제 근로자에게 갱신 청구권을 인정하는 방향을 제시해본다.

- ① 근로계약 기간의 만료에 따라 근로자가 근로계약의 갱신을 요청하는 경우 사용자가 갱신을 거절하려면 그 이유를 근로자에게 통지하여야 하며 그 이유가 정당하여야¹⁰²⁾ 갱

¹⁰¹⁾ 이러한 필자의 견해에 대해, 민법 제152조 제2항이 “중기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.”고 규정하는 바에 따른 원칙에 반하므로 이러한 일반적인 법리에 대한 예외를 인정하기 위한 입법론에 관한 면밀한 검토가 필요하다는 심사의견이 있었다. 그러나 민법에 따른 일반적인 해석과 달리 노동관계는 헌법상 근로권 보장에 충실하게 달리 해석되어야 할 필요와 타당성이 있다.

¹⁰²⁾ ‘정당한 이유’를 요구할지, ‘합리적인 이유’를 요구할지에 관해 면밀한 검토가 요청된다. 우선 이 글에서

신 거절이 가능하다. 갱신 거절의 정당한 이유는 i) 그 근로자가 일해 온 일자리가 계속 유지되지 않거나 고용의 조정이 필요한 경영상의 이유가 있는 경우 또는 ii) 그 근로자의 고용을 계속할 수 없을 정도로 그 근로자에게 책임이 있는 특별한 사정이 있는 경우가 해당한다. 정당한 이유가 있는지 여부는 객관적인 자료를 토대로 사회통념에 따라 판단한다. 정당한 사유의 증명책임은 사용자가 부담한다.

- ② 나아가 사용자가 그 일자리에 대해 근로계약의 기간이 없는 근로계약을 체결하려는 경우, 종전의 기간제 근로자가 기간이 없는 근로계약으로 계속 고용되기를 바란다면, 사용자는 그 근로자와 기간이 없는 근로계약을 체결하여야 할 의무가 있다. 정규직으로 고용형태를 변경하는 경영적 결정에 따라 고용 보장이 충실해져야 하는데, 오히려 고용 보장이 침해되는 상황이 발생할 수 있어, 이를 방지하려는 취지에서 그 의무가 인정된다.

IV. 결론

이 글에서는 갱신기대권 법리의 적정한 운영을 위해 구체적인 해석론을 전개하였다. 갱신기대권 법리가 기간제 근로자의 고용 보장에 큰 기여를 하여 왔음이 인정되지만, 구체적인 해석론이 전개됨에 따라 기간제 근로자의 고용 보장에 미흡하다는 한계가 존재함도 드러난다. 신뢰, 기대 등의 개념 도구를 사용하고 있어 사용자의 의사 또는 재량이 관철될 수 있기에 그러한 한계가 발생한다. 결국 그러한 한계는 갱신기대권 법리에 내재하고 있는 한계이다.

기간제 근로자에게 갱신기대권을 인정하는 법리보다 기간제 근로자에게 갱신청구권을 인정하는 법리가 기간제 근로자의 고용 보장에 더욱 충실할 수 있다. 그러한 법리는 근로계약 기간, 해고 등에 관한 종래의 해석과는 다른 방식의 해석론에 기초하여야 구상될 수 있다. 새로운 해석론의 구상은 헌법이 근로권을 보장하는 취지에 부합할 수 있다. 이러한 점들에 대해 좀 더 면밀한 후속 연구를 전개함으로써 기간제 근로자의 고용 보장 법리가 발전되기를 기대한다.

(논문투고일자: 2022. 5. 19 / 심사 및 수정일자: 2022. 6. 29 / 게재확정일자: 2022. 7. 4)

주제어: 고용보장, 기간제 근로자, 갱신기대권, 갱신거절의 합리적 이유, 근로계약기간

는 해고 이유 제한에서의 표현인 ‘정당한 이유’의 용어를 사용하도록 하겠다.

〈참고문헌〉

- 강선희, “용역업체 변경 시 고용승계기대권” 『노동리뷰』 2021년 7월호, 한국노동연구원, 101-104면.
- 강성태, “기간제근로자의 갱신기대권과 전환기대권”, 『노동리뷰』 2017년 1월호, 한국노동연구원, 127-130면.
- 김홍영, “고령자이며 정년 후 재고용된 기간제 근로자에게 갱신기대권 법리를 인정한 사례”, 『노동리뷰』 2017년 5월호, 한국노동연구원, 95-98면.
- 김홍영, “기간제법의 시행 이후 갱신기대권의 인정 여부 : 서울고등법원 2011. 4. 14. 선고 2010누33971 판결”, 『노동법학』 제41호, 한국노동법학회, 2012. 3, 365-369면.
- 김홍영, “사회통합과 비정규직 노동법의 변화”, 『저스티스』 제134-3호, 한국법학원, 2013. 2, 80-95면.
- 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 II』, 박영사, 2020.
- 노상헌, “기간제 근로계약의 갱신기대권”, 한국노동법학회 편, 『노동판례백선』 제2판, 박영사, 2021, 230-233면.
- 도재형, “기간제법 시행 이후 갱신기대권 법리의 적용 가능성 : 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결”, 『노동법연구』 제42호, 서울대학교 노동법연구회, 2017. 3, 195-219면.
- 도재형·노상헌·최지윤, 『갱신기대권(정규직 전환기대권) 관련 판단기준에 대한 연구』, 중앙노동위원회 학술연구용역 보고서, 2018.
- 박은정, “갱신기대권에 대한 기대의 갱신: 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 판결”, 노동법실무연구회 편, 『노동법실무연구 III』, 2021, 135-156면.
- 박은정, “갱신기대권에 대한 판례의 전개와 발전 -1994-2020년 판례의 흐름을 중심으로-”, 『사회법연구』 제43권, 한국사회법학회, 2021. 4, 255-296면.
- 변성영, “갱신기대권 법리의 재검토”, 『노동법학』 제53호, 한국노동법학회, 2015. 3, 153-187면.
- 변성영, “상대평가에 의한 갱신거절의 정당성”, 『노동법학』 제68호, 한국노동법학회, 2018. 12, 1-26면.
- 유성재 외, 『노동위원회 심판업무 관련 주요 쟁점 사항에 관한 연구』, 중앙노동위원회 학술연구용역사업 보고서, 2021.
- 하갑래, 『근로기준법』, (주)중앙경제, 2019.

<국문초록>

기간제 근로자의 고용 보장 법리

— 갱신기대권 법리의 검토 —

김 홍 영

기간제 근로자에게 근로계약 기간의 만료에도 불구하고 계속 고용될 수 있도록 고용을 보장하는 법리로 갱신기대권 법리가 있다. 갱신기대권 법리는 기간제 근로자의 고용 보장에 큰 기여를 하여 왔다. 이 글에서는 갱신기대권 법리의 구체적인 해석을 전개함으로써 갱신기대권 법리의 적정한 운영을 도모하고자 한다. 갱신기대권이 인정되는지 여부의 판단과 갱신기대권이 인정된다면 갱신 거절에 합리적인 이유가 있는지 여부의 판단을 중심으로 살펴보도록 하겠다.

또한 이 글에서는 갱신기대권 법리가 구체적인 해석과 적용에 있어 기간제 근로자의 고용 보장에 미흡하다는 한계를 드러낼 수 있음을 밝히고자 한다. 신뢰, 기대 등의 개념 도구를 사용하고 있어 사용자의 의사 또는 재량이 관철될 수 있기에 그러한 한계가 발생한다. 그러한 한계는 갱신기대권 법리에 내재되어 있는 한계이므로 그 한계를 극복하기 위해서는 갱신기대권 법리가 아닌 새로운 법리가 필요하다는 점을 제시하고자 한다.

<Abstract>

Legal Principles of Employment Security for Fixed-Term Workers — Review of the Jurisprudence of the Right to Expect Renewal —

Kim, Hong-Young*

There is a jurisprudence on the right to expect renewal as a legal principle that guarantees employment to fixed-term workers so that they can continue to be employed despite the expiration of the labor contract period. The jurisprudence of the right to expect renewal has greatly contributed to the employment security of fixed-term workers. This article intends to promote the proper operation of the right to expect renewal by developing a detailed interpretation of the jurisprudence of the right to expect renewal. We will focus on the judgment of whether the right to expect renewal is recognized and whether there is a reasonable reason for refusing renewal if the right to expect renewal is recognized.

In addition, this article intends to clarify that the jurisprudence of the right to expect renewal may be limited in its specific interpretation and application to guarantee employment of fixed-term workers. Such limitations occur because the employer's will or discretion can be enforced by using concept tools such as trust and expectation. Since such limitations are inherent in the jurisprudence of the right to expect renewal, I would like to suggest that a new jurisprudence is needed to overcome the limitations.

Key Words: *employment security, fixed-term worker, jurisprudence of the right to expect renewal, reasonable reason for refusing renewal, labor contract period*

* Sungkyunkwan University School of Law, Professor